

1501072-16.2019.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... foi apreendida alguma anotação do tráfico; o) não conhecia nenhum dos quatro réus (gravação audiovisual e fls. 7). Em juízo, a testemunha Sylvio Bonfiglioli Pelegio disse que: a) estávamos em patrulhamento pelo Jardim Oratório, onde há tráfico de drogas; b) passou um veículo Agile, jogamos a luz nele e ele acelerou; c) fizemos o retorno e vimos o condutor do Agile ir para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501072-16.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2152744/2019 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 5431797 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3398/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3398/2019 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2152744 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3398/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2152744 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3398/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CLEIDISON FABIANO SANTOS e outros

Data da Audiência:

29/03/2022

Em 29 de março de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e os Defensores reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a

constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presentes os réus Cleidison Fabiano Santos, citado fl. 305, Matheus Victor Mendes, citado fl. 282. Presente o réu Flávio Humberto Butura de Moura, notificado e citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente o réu Daniel Gomes, citado fl. 361. Presente o Advogado Dr. Rodrigo de Raga Culpo (OAB/SP 364.823). Presentes as testemunhas comuns Sylvio Bonfiglioli Pelegio e Gustavo Chiandotti Motosugue. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado Flávio inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado Flávio. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MATHEUS VICTOR MENDES, qualificado às fls. 21 e 47 = 49, FLAVIO HUMBERTO BUTURA DE MOURA, qualificado a fls. 17, DANIEL GOMES, qualificado a fls. 13 e 45, e CLEIDISON FABIANO SANTOS, qualificado a fls. 9 e 43, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 23 de maio de 2019, por volta das 22h:30min, na Travessa José Carlos, nº 6, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de designios, tinham em depósito e guardavam, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 310 pedras de crack, com peso líquido de 138,3g, 175 eppendorfs de crack, com peso líquido de 143,5g, 186 envelopes de cocaína, com peso líquido de 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 58,7g, e 87 invólucros de maconha, com peso líquido de 422,2g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 39/42, e laudo químicotoxicológico de fls. 194/199 (fls. 207/209). Foi concedido aos acusados os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 75/76). A denúncia foi oferecida (fls. 204/206). Os réus foram notificados (réu Matheus - fls. 248 -, réu Cleidison - fls. 250 - e réu Daniel - fls. 280) e apresentaram defesa preliminar (réus Matheus e Cleidison - fls. 263/264 - e réu Daniel - fls. 299/300). A denúncia foi recebida em relação aos réus Matheus e Cleidison (fls. 266). Foi recebida a denúncia em relação ao réu Daniel e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 327/332). O réu Flávio foi citado por edital (fls. 352/353). Nesta audiência, compareceu o réu Flávio ele foi notificado (termo de audiência),

apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi mantida (termo de audiência) e todos os réus foram citados (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Sylvio Bonfiglioli Pelegio (gravação audiovisual) e Gustavo Chiandotti Motosugue (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Cleidison Fabiano Santos (gravação audiovisual), Daniel Gomes (gravação audiovisual) e Matheus Victor Mendes (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Sylvio Bonfiglioli Pelegio (fls. 6) e Gustavo Chiandotti Motosugue (fls. 7) e os réus Cleidison Fabiano Santos (fls. 8), Daniel Gomes (fls. 12), Flavio Humberto Butura de Moura (fls. 16) e Matheus Victor Mendes (fls. 20). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial semiaberto para os réus Cleidson e Daniel e fechado para os réus Flávio e Matheus para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Matheus, Daniel e Flávio Cleidison, em debates, requereu o trancamento da ação penal por violação de domicílio. No mérito, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Matheus, o reconhecimento da causa de diminuição previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para os réus Cleidson, Daniel e Flávio, a redução pela colaboração (no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006), o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito para todos os réus com exceção do réu Flávio, regime diverso do fechado para o réu Flávio e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). A defesa do réu Daniel, em debates, requereu o trancamento da ação penal por violação de domicílio. No mérito, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 27/28). Laudo de constatação provisória (fls. 39/42). Laudo de exame no veículo (fls. 164/171). Auto de entrega (fls. 192/193). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 194/199). Folha de antecedentes (réu Cleidison - fls. 52/53 = 211/212 - réu Daniel -, fls. 54/55 = 213/218 -, réu Matheus - fls. 64 = 227/229) e certidão (réu Cleidison - fls. 65/66 - réu Daniel - fls. 67/68 -, réu Matheus - fls. 72/74 - e réu Flávio - fls. 219/226). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual por invasão de domicílio, pois o flagrante é uma exceção à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), e, a despeito do alegado pela defesa técnica dos réus Matheus, Cleidson e Flavio, havia fundadas suspeitas para o ingresso na residência, porque o réu Cleidson inicialmente, ao notar a presença dos policiais, evadiu-se no seu veículo Agile, abandonou o veículo, correu para o interior de uma viela onde há 100 ou 200 metros havia o tráfego de entorpecentes, entrou na casa e os policiais viram pela janela os réus se escondendo no chão da cozinha e drogas espalhadas pelo chão da sala, o que motivou as testemunhas Gustavo e Sylvio a ingressarem na casa. Inclusive, o réu Matheus disse que acredita que era possível ver as drogas pela janela (gravação audiovisual). Por fim, o simples fato de uma pessoa correr da polícia, a meu ver, já configura a fundada suspeita, com respeito a posições contrárias, pois cidadãos que não tem o que temer não correm ao verem policiais. No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação provisória (fls. 39/42), laudo de exame no veículo (fls. 164/171), auto de entrega (fls. 192/193), exame químico toxicológico definitivo (fls. 194/199) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Gustavo Chiandotti Motosugue, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência; b) em patrulhamento de rotina visualizamos um veículo Agile no contrafluxo para abordá-lo, mas ele se evadiu; c) quando fizemos o retorno, vimos o Cleidson descendo do veículo e acessando uma viela e entrando na última casa; d) pela janela da cozinha

vimos o Daniel, o Flávio, o Cleidson e o Matheus, eles estavam deitados no chão da cozinha tentando se esconder e dava para ver o chão da residência onde haviam diversos entorpecentes; e) nós pedimos para eles saírem, eles não saíram, acessamos a casa, havia diversos entorpecentes espalhados pela sala e os quatro estavam deitados no chão da cozinha; f) há 100 ou 200 metros do local dos fatos há um ponto de entorpecentes; g) havia quase 1 Kg de drogas entre maconha, crack e cocaína; h) entrevistamos um por um separadamente; i) o Daniel disse que era o gerente do tráfico naquele local e estava fazendo fechamento do dia; j) o Cleidson disse que foi receber algumas viagens que havia feito; k) Flávio disse que estava assumindo o próximo turno, era o vapor, o que faria a venda; l) o Matheus não falou nada; m) a informação que tínhamos é que um veículo prata fazia a distribuição das drogas na região, isso é que chamou a nossa atenção; n) não me recordo se foi apreendida alguma anotação do tráfico; o) não conhecia nenhum dos quatro réus (gravação audiovisual e fls. 7). Em juízo, a testemunha Sylvio Bonfiglioli Pelegio disse que: a) estávamos em patrulhamento pelo Jardim Oratório, onde há tráfico de drogas; b) passou um veículo Agile, jogamos a luz nele e ele acelerou; c) fizemos o retorno e vimos o condutor do Agile ir para uma casa em uma viela; d) pela janela vimos entorpecentes espalhados no chão da sala e quatro indivíduos tentando se esconder na cozinha; e) Cleidson disse que era Uber e foi receber as corridas que havia feito; f) o Daniel disse que era o gerente da casa bomba e distribuía entorpecentes; g) o Flávio disse que assumiria o próximo turno; h) o Matheus não falou nada; i) era em torno 1 Kg de drogas entre maconha, cocaína e uma mistura de cocaína e maconha; j) não havia denúncia sobre o tráfico ali; k) a viela é escura, mas dentro da casa haviam lâmpadas; l) a gente sabia que havia tráfico na região, mas não naquela casa em específica; m) depois que a gente deu farol para ele, ele acelerou o veículo, deixou o carro e correu para a casa; n) não conhecia nenhum dos réus (gravação audiovisual e fls. 6). O réu Matheus Victor Mendes, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) havia maconha, cocaína e crack; c) as drogas estavam no chão da sala, eu estava embalando elas e iria sair para entrega-las; d) no momento eu estava sozinho na casa; e) no dia em que eu estava trabalhando depois que chegaram esses dois jovens, quando a polícia entrou; f) não conheço os policiais; g) eles me levaram para fora e havia uma outra pessoa detida; h) chegaram mais três jovens, vi aqui no papel Daniel, Flávio e Cleidson; i) os três chegaram com a polícia e entraram dentro da casa; j) eu não franqueei a entrada dos policiais; k) as luzes do interior do imóvel estavam acesas; l) é bem provável que dava para ver as drogas de fora, porque o vitrô estava aberta; m) não conheço o Daniel (gravação audiovisual e fls. 20). O réu Daniel Gomes ao ser interrogatório, em juízo, disse que: a) não estava lá com as drogas; b) eu não estava na casa; c) eu estava no carro do Agile do Flávio, depois disse que estava com o Cleidson e com o Flávio no veículo; d) eu conheço o Cleidson é cliente da loja e o Flávio já foi lá comprar pneus para o carro; e) não conhecia os policiais; f) os policiais deram voz de parada, paramos, nos revistaram e mandaram entrarmos em uma viela; g) no interior da viela fizeram pergunta sobre o rapaz que estava algemado e perguntou se ele conhecia a gente ou se a gente conhecia nós; h) estávamos indo para um chácara com o Cleidson que é Uber, porque eu iria beber e estávamos indo para uma adega, quando fomos parados pela polícia; i) não conhecia o Matheus (gravação audiovisual e fls. 12). O réu Cleidson Fabiano Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) estávamos eu, o Daniel e o Flávio vindo do Jardim Conquista e fomos abordados pelos policiais; c) eles foram agressivos ao me tirarem do carro; d) estávamos indo para a chácara Fagundes, não me recordo não; e) eu somente iria deixar o Daniel e o amigo dele o Flávio, eles iriam pegar uma bebida na adega e iriam para a chácara onde estava havendo uma festa; f) nunca havia visto os policiais na minha vida; g) não há motivo para os policiais levarem a gente para a casa e dizerem que somos traficantes; h) os policiais nos revistaram e revistaram o carro; i) o Matheus estava com os policiais e falaram que as drogas eram nossa; i) eu tinha aplicativo do Uber e do 99; j) eu troco pneus na borracharia do pai do Daniel há um bom tempo, sou cliente dele (gravação audiovisual e fls. 8). Por fim, o réu Flavio Humberto Butura de Moura, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são

verdadeiros; b) eu estava no carro com o Cleidson e o Daniel; c) eles passaram em minha casa para irmos a uma festa, paramos em uma adega para comprar bebidas e depois fomos abordados por uma viatura, daí eles nos levaram para uma viela onde estava o Matheus e outra equipe policial e disseram que toda a droga era nossa; d) não conhecia os policiais; e) não tem motivo para os policiais terem dito que eles estavam traficando (gravação audiovisual e fls. 16). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação provisória (fls. 39/42), laudo de exame no veículo (fls. 164/171), auto de entrega (fls. 192/193), exame químico toxicológico definitivo (fls. 194/199), como também pelos depoimentos das testemunhas Sylvio Bonfiglioli Pelegio (gravação audiovisual e fls. 6) e Gustavo Chiandotti Motosugue (gravação audiovisual e fls. 7), e pela confissão do réu Matheus Victor Mendes (gravação audiovisual e fls. 20), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento, quando cruzaram com o veículo GM Agile, placas EMG-3675, que era conduzido pelo réu Cleidison, e, com a aproximação da viatura, ele acelerou, abandonou o veículo, acessou uma viela e entrou na última casa. As testemunhas o perseguiram e pela janela da cozinha viram os quatro réus deitados no chão, tentando se esconder, e espalhadas pelo chão e sobre um móvel na sala 310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g, bem como a quantia de R\$ 1.050,00, em cédulas e moedas diversas. O réu Matheus confessou o crime (gravação audiovisual). O réu Cleidson disse ser motorista de Uber e estar levando os réus Flávio e Daniel a uma festa, fato confirmado por estes dois réus, versão totalmente fantasiosa, porque sequer alegaram isso na fase extrajudicial (fls. 8, 12 e 16). Outrossim, os réus Cleidson, Flávio e Daniel afirmaram nos seus interrogatórios que não conheciam as testemunhas e elas não teriam um motivo para incriminá-los. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Matheus Victor Mendes, Daniel Gomes, Cleidison Fabiano Santos e Flávio Humberto Butura de Moura, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao réu Matheus: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g – fls. 27/28, 39/42 e 194/199) permitem aumentar a pena em 1/2, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 64 = 227/229 e 72/74). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, contudo reduzo a sua pena em 1/6, porque ele confessou o crime, passando a pena para (fls. 219/226) 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 2 anos e 1 mês de reclusão, e 208 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque a depender da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, a ser verificada no caso concreto, indubitavelmente se inferiria a dedicação à atividade criminosa, porque nenhuma organização criminosa confere certa quantidade de drogas, neste caso 310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g (fls. 27/28, 39/42 e 194/199), a qualquer pessoa, a não ser que tenha plena confiança nesta pessoa, de onde se inferiria a dedicação à atividade criminosa, já que esta pessoa estaria inserida em algum ponto da cadeia do tráfico de drogas. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3,

a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalcasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” – (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 64 = 227/229 e 72/74), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g – fls. 27/28, 39/42 e 194/199), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do

oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempe pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar

a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g - fls. 27/28, 39/42 e 194/199), fato concreto que impede a substituição. b) Em relação ao réu Daniel: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína,

pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g - fls. 27/28, 39/42 e 194/199) permitem aumentar a pena em 1/2, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 54/55 = 213/218 e 67/68). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduz a pena em 2/3, pelos mesmos motivos já expostos na terceira fase da dosimetria do réu Matheus (item a), que adoto como razão de decidir, passando para 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, no regime inicial fechado, pelos mesmos motivos da dosimetria do réu Matheus (item a), que adoto como razão de decidir. c) Com relação ao réu Cleidison: Pelos mesmos motivos da aplicação da pena do réu Daniel (item b), que adoto como razão de decidir, fixo a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, no regime inicial fechado (fls. 52/53 = 211/212 e 65/66). d) Com relação ao réu Flávio. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g - fls. 27/28, 39/42 e 194/199) permitem aumentar a pena em 1/2, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 219/226). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, contudo aumento a pena deste réu em 1/3, porque ele possui duas reincidências, uma por tráfico de drogas e uma por receptação (fls. 219/226), sendo 1/6 para cada uma das reincidências ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, e 833 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque o réu é multirreincidente (fls. 219/226). O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porque a pena é superior, a oito anos, o réu não ser multirreincidente e a natureza e quantidade das drogas permitem um regime mais rigoroso para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme já fundamentado na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 219/226). Não substituo a pena dos réus, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (310 porções de crack, pesando 138,3g, 175 eppendorfs de crack, pesando 143,5g, 186 porções de cocaína, pesando 152,9g, 156 eppendorfs de cocaína, pesando 58,7g, e 87 porções de maconha, pesando 422,2g - fls. 27/28, 39/42 e 194/199), fato concreto que impede a substituição, além do réu Flávio ser multirreincidente (fls. 219/226). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Cleidison - fls. 10 -, réu Daniel - fls. 13 -, réu Flávio - fls. 18 -, e réu Matheus - fls. 22). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 27/28), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Com relação ao veículo apreendido, ele já foi restituído (fls. 176). Nomeio o réu Cleidson como depositário do bem até o trânsito em julgado desta sentença. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 27/28, 39/42 e 194/199). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO os réus MATHEUS VICTOR MENDES (R.G. nº 54.824.659 - filho de Ana Maria Roma Mendes - fls. 21 e 47 = 49), DANIEL GOMES (R.G. nº 53.673.104 - filho de Gustavo Evangelista Gomes e Avani Laurentino dos Santos - fls. 13 e 45), CLEIDISON FABIANO SANTOS (R.G. nº 38.836.919 - filho de Nilo de Barros Santos e Maria Aparecida Fabiano Santos - fls. 9 e 43) E FLÁVIO HUMBERTO BUTURA DE MOURA (R.G. nº 34.140.858/SP - filho de José Jorge de Moura e Geni Butura de Moura - fls. 16/17), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, respectivamente a, 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, além de 208 dias-multa (réu Matheus), 2 anos e 6 meses de reclusão, no

regime inicial fechado, além de 250 dias-multa (réu Daniel), 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 250 dias-multa (réu Cleidison), e 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 833 dias-multa (réu Flávio), sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual soltos (fls. 75/77). Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas isento os réus Matheus, Cleidison e Flávio em virtude de estarem sendo representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelas defesas e pelos réus foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pelas Defesas e pelos réus. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem." Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.